

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(2) 代位の目的<br/>(a) 売却代金<br/>(b) 賃料・用益物権の対価</p> <p>(7) 担保不動産収益執行の制度を設ける以上、賃料債権等への物上代位は認めるべきではないという見解も有力であったが、抵当権者はどちらの手段も選択できるということになった。</p> <p>(イ) 賃借人(転賃人)は304条の「債務者」には当たらず、この者が取得すべき転賃賃料債権を物上代位の目的とすることはできない(★最決平12.4.14)。</p> <p>(手書きメモ: Bが借りて転賃した分)</p> <p>[26-30-5] 抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転賃された場合は、原則として、賃借人が転賃人に対して取得した転賃賃料債権を物上代位の目的とすることはできない。[○]</p> <p>[30-30-4] 抵当不動産が転賃された場合、抵当権者は、原則として、転賃賃料債権(転賃賃料請求権)に対して物上代位権を行使することができる。[*]</p> <p>(c) 目的物の滅失・損傷により受くべき金銭<br/>(7) 損害賠償請求権(★大判大6.1.22)<br/>(イ) 保険金請求権(★大判明40.3.12、通説)<br/>(手書きメモ: ー物上代位の対象となる)<br/>(d) その他</p> <p>[30-30-3] 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。[○]</p> <p>(3) 物上代位のための差押え(★最判明59.2.2、★最判明60.7.19)<br/>差押えの意義は、物上代位の対象である債権の特定性が保持され、これにより物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面第三者が不測の損害を被ることを防止することにある。</p> <p>＊なお、近時の判例は、従来のものと異なり、「二重弁済の危険から第三債務者を保護」するところにあるとしている(★最判平10.1.30)。</p> <p>ー物上代位の目的となる債権を第三者が先に差し押さえたにどまる場合には抵当権者はなお物上代位をなし得る。</p> <p>＊判例は、差押えと転付命令を區別し、転付命令は「払渡し又は引渡し」に当たるが、差押えはこれに当たらないという判断を基礎としている。</p> <p>＊判例は、目的債権が特定性を維持しつつ債務者の財産に帰属していることを物上代位の要件としているものといえる。</p> <p>4 抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡<br/>抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれない)(★最判平10.1.30、★最判平10.2.10)。</p> <p>[26-30-1] 対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲渡人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自らの債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。[○]</p> <p>5 一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位に基づく差押えが競合した場合<br/>両者の優先は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、差押命令の第三債務者への送達が抵当権設定登記より先であれば、抵当権者は配当を受けることができないと解<br/>ご提示いただいた画像「image_6498e6.jpg」の内容を文字起こししました。</p> <p>行政書士試験対策講座<br/>すべである(★最判平10.3.26)。</p> <p>6 物上代位と転付命令<br/>★最判平14.3.12</p> <p>転付命令が第三債務者に送達する時までには抵当権者が転付命令債権の差押えをしなかったときは、抵当権者が転付命令債権について抵当権の効力を主張することはできない。</p> <p>(手書きメモ: ※転付命令は払渡し・引渡しにあたる)</p> <p>7 物上代位と相殺<br/>★最判平13.3.13</p> <p>抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後には賃借人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。</p> <p>(手書きメモ: ※賃料債権が勝手に質し付けなように、債権を守るため)</p> <p>[26-30-2] 対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。[○]</p> <p>★最判平14.3.28</p> <p>敷金が授受された賃貸借契約に基づく賃料債権について、抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合でも、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。</p> <p>(手書きメモ: 敷金は当然に賃借人が守る！)</p> <p>8 物上保証人の求償権(賃借人に関する351条の準用)<br/>★最判平2.12.18</p> <p>債務者の委託を受けて自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ債務者に対して求償権を行使することはできない。</p> <p>第2節 抵当権の効力 (A)<br/>■総説<br/>◇ 抵当権侵害に対する効力<br/>(1) 抵当権も物権であるから、その侵害があれば、抵当権者は物権的請求権を行使することによって侵害を排除し、また、それによって損害が生じた場合には、不法行為に基づいて損害賠償を請求することができる。ただし、抵当権は優先弁済請求を中心とする目的物の価値支配権を認めるにすぎないものであるから、通常の利用では抵当権侵害にならないという特殊性がある。<br/>(2) 物権的請求権<br/>(a) 侵害行為停止の請求<br/>(7) 侵害といえるためには、実際の損害により目的物の交換価値が被担保債権額を担保しない程度にまで至る必要はなく、被担保債権が担保されなくなるおそれを生ずれば足りる。<br/>(イ) 抵当設定受取人や第三者による不法な差出しに対して、抵当権者は、物権的請求権を行使して差出し禁止の請求をすることができる(★大判明8.10.21)。<br/>抵当権者は、分擔取出した付加一俵物を抵当不動産の所在場所に戻すように請求することができる。<br/>(b) 妨害排除請求<br/>抵当権者は目的物の占有権がなく、第三者が占有しているというだけでは抵当権の侵害があるとはいえないとして、明渡請求を否定するのが過去の判例であったが(★大判明9.6.15、★最判明3.3.22)、現在では一定の要件の下で肯定するに至っている(★最大判平11.11.24、★最判平17.3.10)。<br/>(7) 抵当権設定後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者がいる場合、①占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、②その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときに、妨害排除請求をなし得る(★最判平17.3.10)。<br/>(手書きメモ: ー占有権を追い出す(対価払わせる等))<br/>'・' 抵当不動産の所有者は、抵当不動産を使用又は収益するに当たり、抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており、抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されない。<br/>"[3-29-4]" 抵当権設定登記後に設定者が抵当不動産を他人に賃貸した場合において、その賃料債権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、賃借人の占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、賃借人に対して、抵当権に基づく妨害排除請求を請求することができる。 [○]<br/>(イ) 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当権者は、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合に、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。<br/>(手書きメモ: ー設定者がだらけなく占有者がひどいとき)<br/>"[29-31-2]" 第三者が抵当不動産を不法占有することによって同不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求権が認められるが、抵当権は占有を目的とする権利ではないため、抵当権者が占有者に対し直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることは常にできない。 [*]<br/>(3) 不法行為に基づく損害賠償請求権<br/>(a) 損害の発生<br/>損害といえるためには、抵当権の侵害により目的物の価値が減少し、その結果被担保債権が十分に満足されなくなったことが必要<br/>(b) 損害賠償の時期<br/>抵当権実行前でも、弁済期後であれば抵当権の実行が可能であるから、不法行為時ではなく(損害賠償請求訴訟時の目的物の時価を基準にして損害賠償を請求することができる(★大判明7.5.21、通説)。<br/>(手書きメモ: 計算は出来るよ)<br/>(4) 期限の利益の喪失(137条2号)<br/>(5) 増損担保請求権<br/>特約なき場合にも解釈によりこれを認める見解が有力である。<br/>(6) 債権者の明渡請求権の代位行使<br/>判例(★最大判平11.11.24)は、①不法占有者の存在自体が競売手続の進行を著し難化を下落させるおそれがあるなど、交換価値の実現が妨げられるような状況があるときは、抵当権に対する侵害と評価できる。そして、②抵当権侵害</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



[illegible]

1 定義  
代価弁済とは、抵当不動産につき、所有権又は地上権を買い受けた者（第三取得者）が、抵当権者の請求に応じてこれに代価を弁済したときには、抵当権はその第三取得者のために消滅するという制度をいう。

2 要件  
① 抵当不動産につき所有権又は地上権を買い受けること  
② 抵当権者の請求  
③ 代価の弁済  
抵当権者からの請求に応じて代価を弁済した場合には、抵当債権の全額弁済でなくとも、抵当権が消滅する。（手書き：地上権、質借権はどうなる？）

3 効果  
(1) 第三取得者が所有権の取得者であれば、抵当権は消滅するが、地上権の取得者であれば抵当権は消滅せず、地上権の負担付きの抵当権となり、抵当権が実行されても、買受人は地上権者に対抗できないという優先を有するにとどまる。  
(2) 債務者は、第三取得者が代価弁済した範囲で債務を免れるが、残余債務は、無担保債権となる。

第379条（抵当権消滅請求）  
“抵当不動産の第三取得者は、”第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。  
（手書き：不動産の取得者から抵当権者に請求。10-100万円払うので消して。債務者からは不可。似ているが逆）

1 抵当権消滅請求権者  
(1) 原則として抵当不動産の所有権を取得した者（第三取得者）である。  
(2) 主たる債務者、保証人及びその承継人（380条）、停止条件付第三取得者（381条）、贈与の受贈者（★裁判7.11.10）は、抵当権消滅請求権を有しない。  
(3) 代価弁済と異なり、これらの権利を「買い受けた」ことは必要でなく、無償取得でもよい。もっとも、特定承継による取得に限られ、相続などによる包括承継によって権利を取得した者は含まれない。  
（手書き：→ 贈与でもよい（事案など））

2 効果  
抵当権は消滅し、所有権は抵当権の負担のない完全なものとなる。請求金額が被担保債権額に満たないときは、残額は無担保債権となる。

第380条（抵当権消滅請求）  
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。  
（手書き：379条のほそく。債務者はあくまで買い取った者のみ）

第381条（抵当権消滅請求）  
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

◇ 趣旨  
停止条件付きで抵当不動産につき所有権を取得した者は、条件が成就するまでは単に期待権を持つにとどまり、これらの権利を現実的に取得した者とはいえないから、抵当権消滅請求権者から除外した。

【2枚目（右側）の文字起こし】  
第382条（抵当権消滅請求の時期）  
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

第383条（抵当権消滅請求の手続）  
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。  
取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面  
抵当不動産に関する登記事項証明書（現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。）  
債権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

第384条（債権者のみなし承諾）  
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。  
その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。  
その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定（民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の勝本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。）が確定したとき。  
（手書き：※ 2か月以内にしないといけない。2か月過ぎると承諾が確定しちゃう…）

第385条（競売の申立ての通知）  
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

第386条（抵当権消滅請求の効果）  
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。  
（手書き：みんなに払ったら消えるよ）

第387条（抵当権者の同意の登記がある場合の質貸借の対抗力）  
① 登記をした質貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意を、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。  
② 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

1 趣旨  
質押物件については、質借人が入居していることが物件の価値を高める、ということもある。そうした、自らの優先権を失わせて質借権を引き受けてもメリットがあると抵当権者が判断した質借権に対抗力を認めることは、抵当権者ほか、抵当権設定者や質借人の利益にもかなるものになるということで考え出されたのが、この制度である。

2 要件

- ① 抵当権に劣する質借権について、その登記があること
- ② その質借権の登記前に登記した抵当権を有するすべての者が質借権に対抗力を付与することにつき同意していること
- ③ その同意につき登記があること

3 効果

- (1) 本来、抵当権に後れる質借権は抵当権者に対抗することができないが、上記の要件を満たす場合には、抵当権に後れる質借権を抵当権者に対抗することが可能となる。
- (2) 質借権に先行する複数の抵当権者がある場合は、すべての抵当権者の同意がなければ質借権は最先順位とならない。

第388条(法定地上権)

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

1 趣旨

我が民法の下では、土地と建物は別個の不動産とされるため、両者は独立して抵当権の目的となる。それゆえ、土地又は建物の一方に抵当権が設定され、それが実行されて所有者を異にする場合が生じる。この場合に、建物は土地の上に存するものである以上、その土地を利用する法的権原なくしては存立し得ないが、建物所有者が抵当権設定前に自己所有の土地の上に建物のための土地利用権を設定すること(自己借地権)は、原則により認めたい(179(手書き・施工後は建物所有者の義務ある))

2 成立要件

- ① 抵当権設定当時、建物が存在すること
  - (a) 更地に抵当権が設定された場合(手書き: 抵当権は価値が低い)
  - (イ) 更地に抵当権設定後に建物を建てた場合、法定地上権は成立しない(★大判大4.7.1)。(手書き: → 工建物に入も付けられる)
  - (イ) 更地に抵当権が設定された場合、当事者間で将来建物を建築したときは地上権を設定したものとみなすとの合意があっても、法定地上権は成立しない(★最判昭36.2.10)。もっとも、建物の建築が開始され、抵当権者が法定地上権の発生を抵当権の評価の基礎とした場合には、法定地上権は成立する可能性がある。
  - (ウ) 1番抵当権設定時には更地であったが、2番抵当権設定時には建物が築造された場合、2番抵当権が実行されても法定地上権は成立しない(★大判昭11.12.16)。1番抵当権と2番抵当権の順位の変更後に抵当権が実行された場合も、同様である(★最判平4.4.7)。

(エ) 更地に抵当権設定後に築造された建物の上にさらに抵当権が設定され、建物抵当権、土地抵当権の順に抵当権が実行された場合、建物抵当権実行によりいったん建物の買受人は法定地上権を取得するが、土地抵当権が実行されると、その法定地上権は土地の買受人に対抗し得ない(★大判大12.2.8)。

(b) 建物が再築された場合

- (ア) 抵当権設定当時建物が存在していれば、その後建物が滅失し、再築された場合でも、旧建物を基準として法定地上権は成立する(★大判昭10.8.10)。
- (イ) 新建物が堅固なものであっても、抵当権者の利益を害しない認められる特段の事情がある場合は、新建物を基準として法定地上権が発生する(★最判昭52.10.11)。
- (ウ) 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物を取り壊され、その土地の上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた等の特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しない(★最判平9.2.14 全体価値考慮説)。

[23-30-4] Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったため、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。 [○]

(c) 建物に保存登記がなくても(★大判昭14.12.19)、また移転登記がなされていなくても(★最判昭48.9.18)、法定地上権は成立する。

② 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること

- (a) 抵当権設定当時、土地・建物が別人に帰属していれば、既に契約によって土地利用権が設定されているはずであるから、法定地上権を成立させる必要はない(★大判昭38.6.28)。

[1-30-エ] A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の両建物が存在している。Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に質借権に基づいて甲土地に両建物を築造していたCから当該抵当権の設定後に両建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、両建物のために甲土地の上に当然に発生する。 [×]

(b) 借地上の建物に抵当権が設定された場合、土地と建物の所有権が同一人に帰属するに至っても、法定地上権は成立しない。混同の例外として従来の借地権が存続する(★最判昭44.2.14)。

(c) 抵当権設定後、土地所有者と建物所有者がとが異なるに至っても、法定地上権は成立する(★大連判大12.12.14)。

(d) 実体的には土地・建物は同一人に帰属するが、その登記名義が異なる場合でも、法定地上権は成立する。(手書き: → 実体を守る)

→ ア 土地に抵当権を設定したが、建物は前主名義のままになっていた場合(★最判昭48.9.18)

イ 土地が前主名義のまま、建物に抵当権が設定されていた場合(★最判昭53.9.29)

[20-31-2] AはBに金銭を貸し付け、この資金債権を担保するためにB所有の土地の上に建っているB所有の建物に抵当権の設定を受けて、その登記を備えた。実行時において所有の土地の登記名義はCであった場合でも、抵当権実行により買受人Dのために法定地上権が成立する。 [○]

(e) 土地について1番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なっていれば、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に土地について2番抵当権が設定されて実行されたとしても、土地建物のための法定地上権は成立しない(★最判平2.1.22)。

[23-33-2] AがBから土地を借りてその土地の上に建物を所有している場合において、Bは、その土地に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したが乙抵当権は消滅せず、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。 [×]

[23-30-3] AがBから土地を借りてその土地の上に建物を所有している場合において、Aは、その建物に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったため、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。 [×]

共有と法定地上権の成否(手書き: 他人の共有者のものを勝手に譲ることはできない)

① 土地共有 → 法定地上権不成立

- ① 土地がABの共有で、建物がAの単独所有の場合に、Aの土地持分に抵当権が設定され実行されても、法定地上権は成立しない(★最判昭29.12.23)。
- ② 土地がABの共有で、建物がAの単独所有の場合に、建物に抵当権が設定され実行されても、法定地上権は成立しない。
- ③ 土地がABCの共有で、建物がAと別の者との共有である場合、ABCがAの債務を担保するためにそれぞれの持分に共同して抵当権を設定していた場合であっても、他の共有者(B/C)がその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、土地共有者(A)の持分に委ねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がない限り、共有土地について法定地上権は成立しない(★最判平6.12.20)。

② 建物共有 → 法定地上権成立

- ① 土地がAの単独所有で、建物がABの共有の場合に、土地に抵当権が設定され実行された場合、法定地上権は成立する(★最判昭46.12.21)。

[23-30-5] AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったため、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。 [×]

② 土地がAの単独所有で、建物がABの共有の場合に、Aの共有持分に抵当権が設定され実行された場合、法定地上権は成立する。

(3) (まとめ)

土地AC共有、建物AC共有 → 法定地上権成立

土地AC共有、建物AB共有 → (原則として) 法定地上権不成立

[26-29-オ] A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同土地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各自の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を取得した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。[○]

- ③ 土地・建物の一方又は双方に対する抵当権設定  
④ 抵当権実行によって建物所有権者と土地所有権者とが異なること

抵当権の実行に限らず、抵当権者でない他の債権者の申立てにより強制競売があった場合にも、法定地上権は成立する(★大判大3.4.14)。

### 3 法定地上権の内容

(1) 地代

当事者の請求によって裁判所が定める(後段)。当事者の協議が成立すればそれによる。  
(2) 法定地上権の成立を特約によって排除することは認められない(★大判明41.5.11)。

(手書きメモ)  
ア 所有 イ 所有 ウ A・B・C(Cのために)債務者＝C 抵当権設定  
① A・B・C共有の土地に抵当権設定  
② Gに土地持分常利  
③ 一部な建物に法定地上権成立?  
④ 一番平和な確定か

### 法定地上権成立

#### 第389条(抵当地の上の建物の競売)

① 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。  
② 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合等には、適用しない。

### 1 要件

- ① 土地に抵当権を設定した当時、建物が存在せず、その後土地に建物を築造したこと  
② 建物所有者が、抵当地を占有するにつき抵当権者に対抗し得る権利を有しないこと

### 2 効果

(1) 抵当権者は、土地と建物を一括して競売することができる(1項本文)。  
→ 抵当権者が土地のみを競売に付するか、土地と建物を一括競売に付するかは自由であり、一括競売の義務はない(★大判大15.2.5)。

[23-30-1] Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなくなった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は取去されなければならないことから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。[×]

(2) 一括競売した場合であっても、抵当権者は土地の競売代金だけから優先弁済を受けるにとどまり、建物の競売代金については一般債権者としての配当を受ける(1項ただし書)。

第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)  
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

[20-31-2] AはBに金銭を貸し付け、この貸金債権を担保するためにB所有の土地の上に建っているB所有の建物に抵当権の設定を受けて、その登記を備えた。実行時において土地の登記名義はCであった場合でも、抵当権実行により買受人Dのために法定地上権が成立する。[○]

(e) 土地について1番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なっていれば、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に土地について2番抵当権が設定されて実行されたとしても、土地建物のための法定地上権は成立しない(★最判平2.1.22)。

[23-33-2] AがBから土地を借りてその土地の上に建物を所有している場合において、Bは、その土地に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したが乙抵当権は消滅せず、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。[×]

[23-30-3] AがBから土地を借りてその土地の上に建物を所有している場合において、Aは、その建物に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。[×]

### 共有と法定地上権の成否

#### (1) 土地共有 → 法定地上権不成立

- ① 土地がABの共有で、建物がAの単独所有の場合に、Aの土地持分に抵当権が設定され実行されても、法定地上権は成立しない(★最判昭29.12.23)。  
② 土地がABの共有で、建物がAの単独所有の場合に、建物に抵当権が設定され実行されても、法定地上権は成立しない。

③ 土地がABCの共有で、建物がAと別の者の共有である場合、ABCがAの債務を担保するためにそれぞれの持分に共同して抵当権を設定していた場合であっても、他の共有者(BC)がその持分に基づき土地に対する使用収益権を事実上放棄し、土地共有者(A)の処分にあてまわったことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がない限り、共有土地について法定地上権は成立しない(★最判平6.12.20)。

#### (2) 建物共有 → 法定地上権成立

① 土地がAの単独所有で、建物がABの共有の場合に、土地に抵当権が設定され実行された場合、法定地上権は成立する(★最判昭46.12.21)。

[23-30-5] AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。[×]

② 土地がAの単独所有で、建物がABの共有の場合に、Aの共有持分に抵当権が設定され実行された場合、法定地上権は成立する。

### (3) (まとめ)

土地AC共有、建物AC共有 → 法定地上権成立

土地AC共有、建物AB共有 → (原則として) 法定地上権不成立

### (手書きメモ)

他の共有者の持分を勝手に譲らせることはできない

### 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

### 第392条(共同抵当における代価の配当)

① 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

② 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

### 1 趣旨

同一債権の担保として数個の不動産上に抵当権が設定される場合(共同抵当)、各不動産は被担保債権の金額を担保するので、担保力が増し、抵当権者にとって有利である一方、後順位抵当権者が十分な弁済を受けられるかどうかは共同抵当権者の意思に左右されるという弊害が生じる。そこで、共同抵当権の本来的機能を制限し、後順位抵当権者に特別な権利を認めることによって、その保護を図った。

### 2 同時配当(1項)

(1) 「同時にその代価を配当すべきとき」とは、共同抵当の目的物が、同一の競売手続によって競売され、その代価が同時に配当される場合である。

(2) 共同抵当権者は、各不動産にその価額に応じて被担保債権額を割り付け、この割付額の範囲内でのみ優先弁済を受ける(按分主義)。

(3) 後順位抵当権者が存在しない場合にも、本案は適用される(★大判昭10.4.23)。

### (図解)

債務者 B → 1番抵当3,000万円 → A

甲地 (5,000万円) → C 2番抵当1,500万円

乙地 (2,000万円) → D 2番抵当1,000万円

丙地 (1,000万円) → E 2番抵当500万円

同時配当の場合、Aは甲地から1,875万円、乙地から750万円、丙地から375万円の弁済を受ける。C・D・Eは、各不動産の残余価値から弁済を受ける。

※テキスト本文と計算結果に若干の相違がある可能性があります(図中の数値に基づく按分計算: 5:2:1の比率)。

### 3 異時配当(2項)

#### (1) 代位権の発生

- (a) 共同抵当の目的物のうち、1つの不動産の代価を配当するときに、共同抵当権者は被担保債権全額につき優先弁済を受けることができる(前段)。  
(b) 次順位にある抵当権者は、他の不動産につき、同時配当が行われたとすればその不動産が負担すべきであった額に満つるまで、共同抵当権者に代位して優先弁済を受けることができる(後段)。



優先弁済を受けることができる(後段)。

(2)「次順位の抵当権者」  
次順位者に限られず、広く共同抵当権に対して後順位の抵当権を有する者を意味する(★大判大11.2.13)。

(図解)

債務者 B ←—— 1番 抵当 3,000万円 —— A

甲地 (5,000万円) ←—— C 2番 抵当 1,500万円

乙地 (2,000万円) ←—— D 2番 抵当 1,000万円

丙地 (1,000万円) ←—— E 2番 抵当 500万円

異時配当(甲地のみを実行)した場合、Aは甲地から3,000万円全額の弁済を受ける。Cは、同時配当がなされたならばAが乙地・丙地から弁済を受けるべき金額に満つるまで、Aに代位することができる。すなわち、乙地につき1,000万円、丙地につき500万円を限度としてAの抵当権を代位行使できる。

(3) 物上保証人との関係

392条2項は、共同抵当物件がすべて債務者所有である場合、又はすべて物上保証人所有である場合(★最判平4.11.6)に適用され、共同抵当不動産の一方が物上保証人の所有である場合は、弁済者代位規定(501条)が優先する(判例・通説)。

(a) 物上保証人と債務者所有不動産上の後順位抵当権者との関係

i 債務者所有の甲不動産と物上保証人所有の乙不動産とが共同抵当の目的になっており、甲不動産に後順位抵当権者がいた場合、乙不動産に対する抵当権が実行されると、物上保証人は甲不動産につきその後順位抵当権者に優先して代位できる(★大判昭4.1.30)。

ii 甲不動産上の抵当権が実行されたとき、後順位抵当権者は、物上保証人所有の乙不動産に対する抵当権について代位できない(★最判昭44.7.3)。

(b) 物上保証人と物上保証人所有不動産上の後順位抵当権者との関係

物上保証人が債務者所有の不動産に代位するとき、抵当権に対して物上代位をするのと同じように、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した抵当権から、優先的に弁済を受けることができる(★大判昭11.12.9)。

→ 債務者所有の不動産上にも後順位抵当権者がいる場合、物上保証人所有不動産上の後順位抵当権者は、債務者所有不動産上の後順位抵当権者に優先する(★最判昭60.5.23)。

第393条(共同抵当における代位の付記登記)

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)

① 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

② 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない、この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

第395条(抵当建物使用者の引渡し義務)

① 抵当権に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者で次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。))は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

1 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

2 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

② 前項の規定は、買受人の買受けの時から相当の期間を定めてその対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

1 趣旨

賃借権が抵当権に対抗できない場合に、抵当権が設定された建物に生活又は営業の本拠を置く賃借人が、抵当権が実行され、買受人に所有権が移転した時点で即時に当該建物の明渡しを強いられるという不利益を緩和し、賃借人の保護を図るというものである。

2 明渡義務の対象除外者

① 不法占有者

② 差押え後に占有を始めた者

3 明渡義務の法律構成

明渡義務期間中の占有者と落札者との間の法律関係については、文字どおりの明渡義務であって、ここに賃貸借関係が成立することはない。賃借人は買受人の代金納付時に占有権原を失い不法占有者となるが、新所有者に対して直ちに明け渡すという義務を負わずに、明渡請求を免れられるという形となる。

[20-31-5] AはBに金銭を貸し付け、この貸金債権を担保するためにB所有の土地の上に建っているB所有の建物に抵当権の設定を受けて、その登記を備えた。抵当権設定登記後にBが同抵当建物をHに賃貸してHがその旨の登記を備えた場合、抵当権実行による買受人からの明渡請求に対して、賃借人Hは、明渡しまでの使用の対価を支払うことなく、6か月の明渡義務期間を与えられる。[×]

[21-30-エ] Hは甲建物を抵当権の実行による競売により買い受けたが、甲建物には、抵当権設定登記に従前の所有者より賃借したIが居住している。HはIに対し、相当の期間を定めて甲建物の賃料1か月分以上の支払いを催告したが、期間経過後もIが賃料を支払わない場合には、Hは買受け後6か月を経過した後、Iに対して建物の明け渡しを求めることができる。[×]

ご提示いただいた5枚の画像の内容を順に文字起こしました。行政書士試験対策のテキストで、第3節「抵当権の消滅」から第4節「根抵当」に関する内容です。

【枚目 p.195】

### 第3節 抵当権の消滅

#### ■総論

##### 1 一般的消滅原因

- ① 物権共通の消滅原因(目的物の滅失、混同、抵当権の放棄等)
- ② 担保物権共通の消滅原因(被担保債権の弁済、免責の債務引受等)
- ③ 抵当権の実行(競売)
- ④ 代価弁済(378条)、抵当権消滅請求(379条以下)

##### 2 特殊な消滅原因

- ① 抵当権の消滅時効(396条)
- ② 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅(397条)
- ③ 抵当権の目的たる用益権の放棄(398条)

##### 第396条(抵当権の消滅時効)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時に消滅しない。

##### ◇ 抵当権の消滅時効

- (1) 債務者・物上保証人との関係  
抵当権は、被担保債権と同時に消滅しない。  
(2) 第三取得者・後順位抵当権者との関係  
396条の適用はなく、抵当権は熟立して20年の消滅時効にかかる(166条2項、★大判昭15.11.26)。

##### 第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

##### ◇ 趣旨

取得時効は原始取得であるから、所有権だけでなく抵当権も消滅するはずであるが、自ら義務や責任を負っている債務者又は抵当権設定者にまでこれを認めるのは妥当でないから、これらの者を除外した。

[21-29-2] Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得した場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。[○]

##### 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

##### ◇ 注意

- (1) 地上権又は永小作権の放棄を抵当権者に対抗し得ない結果、抵当権者はそれらの権利を存在するものとして競売に付することができる。
- (2) 地上権の放棄も土地所有者との関係では有効であり、土地の返還も認められる。

(3) 借地上の自己の建物に抵当権を設定した後で借地権を放棄したり(★大判大11.11.24)、借地契約を合意解除しても(★大判大14.7.18)、抵当権者には対抗できない(本条類推適用)。

### 第4節 根抵当

#### 第398条の2(根抵当権)

- ① 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができる。
- ② 前項の規定による抵当権は「根抵当権」という。担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
- ③ 前項の規定に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。))は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

#### 1 趣旨

継続的に取引を起している当事者間では、債権・債務が発生・消滅を繰り返し、その額も常に変動する。このように債権が特定されない以上、通常の抵当権を設定することは不可能であり、もしこれを担保するとすれば、抵当権の設定・抹消を連続的に行わなければならないことになる。そこで、かかる煩雑さを回避するため、根抵当権の規定が設けられた。

#### 2 定義

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、一定の極度額の限度において担保する抵当権をいう。

##### 3 付役性の緩和、随伴性の緩和

- (1) 成立に関する付役性の緩和  
具体的な特定の債権が発生する前に、将来発生する債権のためにあらかじめ抵当権を設定することができる。
- (2) 消滅に関する付役性の緩和  
元本の確定前には、被担保債権を弁済しても根抵当権は消滅しない。
- (3) 随伴性の緩和  
被担保債権は、増減変動するため、その増減変動する被担保債権と抵当権との結び付きが弱くなっている。したがって、増減変動するその債権が譲渡されたからといって、根抵当権がそれに随伴して移転するということはない。

#### 4 被担保債権の限定

「一定の範囲に属する不特定の債権」(1項)が被担保債権とされる。債権が不特定であっても「一定の範囲に属する」ことが必要とされ、包括根抵当(当事者間で生ずる一切の債権を担保するもの)は否定される。

- ① 債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権(2項)  
→ 当座貸越契約、継続的手形割引契約、継続的手形貸付契約等の特定の契約から生ずる債権

##### ② その他債務者との一定の種類取引によって生ずる債権(2項)

- 当座貸越取引、手形割引取引、手形貸付取引、消費貸借取引等、取引の種類が限定されている場合
- ③ 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権(3項)  
→ 継続的に発生が予想される不法行為(工場排水による公害等)による将来の損害賠償請求権
- ④ 手形上若しくは小切手上の請求権(3項)  
→ 債務者が第三者のために提出・裏書・保証した手形・小切手(圓形手形・小切手)が転々流通して債権者が取得した請求権
- ⑤ 電子記録債権(3項)

#### 5 根抵当権の設定

- (1) 根抵当権者と設定者の合意による
- (2) 原則:登記が対抗要件(177条)

例外:登記が効力発生要件

- ① 被担保債権の範囲の変更(398条の4第3項)

- ② 債権者の変更(398条の4第3項)
- ③ 確定期日の変更(398条の6第4項)
- ④ 特約共同根抵当関係(398条の16、398条の17)等

#### 第398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)

- ① 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の金額について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- ② 債権者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したもののについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らずに取得したもののについては、これを行使することを妨げない。
- 1 債権者の支払の停止
- 2 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
- 3 抵当不動産に対する競売の申立て又は強制執行による差押え

##### ◇ 優先弁済の限度

根抵当権に375条の適用はなく、利息・遅延利息は極度額内においては無制限に担保されるが、極度額を超えては一切担保されない。

[2-29-1] 被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。[×]

[4-29-4] 機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を保ち、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲「BのAに対する材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。本件根抵当権につ

#### 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

- ① 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
- ② 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はない。
- ③ 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったとは、その変更をしなかったものとみなす。

#### ◇ 趣旨

根抵当権は、極度額という枠の範囲において目的物の担保価値を支配する権利として換価性を有するから、基本契約を離れてその根抵当権が担保する債権の範囲を変更したり、債務者を変更することが認められる。もっとも、元本が確定すれば普通抵当権とほぼ同様となるから、確定前しか変更は認められない(1項)。また、極度額を越えられれば後順位抵当権者その他の第三者を害することもないので、これらの者の承諾は不要とされた(2項)。さらに、変更は根抵当権の種としての内容を決定するものと考えられるので、変更に関する登記には効力発生要件としての意味が与えられている(3項)。

[28-31-1] Aは債務者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売却代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。元本確定前、A・Bは協議により、被担保債権の範囲にA・B間の金銭消費貸借取引に係る債権を加えることと合意した。A・Bがこの合意を後順位抵当権者であるCに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更についてCの承諾が必要である。[×]

[29-22] 元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。[×]

[4-29-2] 機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を保ち、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲「BのAに対する材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。本件根抵当権につ

#### 第398条の5(根抵当権の極度額の変更)

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

#### 第398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)

- ① 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
- ② 第398条の第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- ③ 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
- ④ 第1項の期日の変更についてはその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

【枚目 p.199】

[2-29-3] 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。[○]

#### 第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

- ① 「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」「元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
- ② 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債権を行使することができない。

いときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)

- ① 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
- ② 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
- ③ 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
- ④ 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
- ⑤ 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。

第398条の10(根抵当権者又は債務者の会社分割)

- ① 元本の確定前に根抵当権者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
- ② 元本の確定前にその債務者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
- ③ 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。

第398条の11(根抵当権の処分)

- ① 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができる。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
- ② 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

◇趣旨

根抵当権は、確定前は被担保債権から独立した存在なので、次条以下において普通抵当権とは異なった処分方法を規定している(全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡)。そこで、本条は普通抵当権の処分方法である376条1項の処分はできないものとした。もっとも、転抵当は根抵当権の種の支配権としての内容を侵害しないので、認められた。

第398条の12(根抵当権の譲渡)

- ① 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
- ② 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
- ③ 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

1 根抵当権の全部譲渡(1項)

全部譲渡は、根抵当権の把握している一定量の担保価値、いわゆる根抵当の種の譲渡である。

[28-31-3] Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA-B間の継続的売買に係る売却代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てCに譲り渡すことができる。[○]

2 根抵当権の分割譲渡(2項)

分割譲渡とは、根抵当権を2個の根抵当権に分割し、その1つを根抵当権設定者の承諾を得て譲渡することという。

第398条の13(根抵当権の一部譲渡)

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことという。以下この節において同じ。)をすることができる。

◇根抵当権の一部譲渡

- (1) 元本の確定前に、根抵当権は設定者の承諾を得て一部譲渡をすることができる。
- (2) 譲受人は譲渡人と共に根抵当権を共有する。

第398条の14(根抵当権の共有)

- ① 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、そのために定める。
- ② 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

◇趣旨

根抵当権につき、転抵当以外の376条の処分をすることは認められないが(398条の11)、根抵当権を有する者が、先順位の普通抵当権者から順位の譲渡・放棄の利益を受けることはできる。かかる処分の利益を受けている根抵当権を、譲渡あるいは一部譲渡した場合、譲受人はその処分の利益を受け得ることを規定する。

第398条の16(共同根抵当)

第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

◇趣旨

根抵当権では、被担保債権の範囲が取引関係の拡大に応じて無制限に拡大し得るから、複数の不動産上に根抵当権が設定された場合は、各不動産ごとに極度額を定めて各不動産の個別の負担とする(累積的負担)を原則とした(398条の18)。もっとも、法律上は数筆の土地であっても、社会経済的には同一財産として扱われ得る場合(建物と敷地、隣接する数筆の土地等)には、なお共同担保として根抵当権を設定する現実的必要性はあり、この場合に累積的負

第398条の17(共同根抵当の変更等)

- ① 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
- ② 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

第398条の18(累積根抵当)

数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

◇累積根抵当

- (1) 累積根抵当とは、各不動産につきそれぞれ極度額を定め、根抵当権者の被担保債権を累積負担させるものである。
- (2) 数個の根抵当権は、それぞれ独立した根抵当権であり、後順位抵当権者の代位は生じない。

第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

- ① 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
- ② 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
- ③ 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

[4校目 p.203]

[4-29-1] 機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶに当たり、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する材料供給にかかると継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。本件根抵当権につ

第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)

- ① 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
    - 1 根抵当権者が抵当不動産について売却若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続の開始若しくは担保不動産収益執行の手続の開始又は差押えがあったときに限る。
  - 2 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
  - 3 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
  - 4 債務若しくは被担保債権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
- ② 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものととしてその根抵当権又はこれを目指す権利を取得した者があれば、この限りでない。

[21-29-9] Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。Aの抵当権が根抵当権である場合において、Bが破産手続開始の決定を受けたときは、被担保債権は確定して満足し、根抵当権は確定的に消滅する。[×]

第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求)

- ① 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額を加えた額に減額することを請求することができる。
- ② 第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。

[28-31-4] Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA-B間の継続的売買に係る売却代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額を加えた額に減額することを請求できる。[○]

[2-29-5] 根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。[×]

[4-29-3] 機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶに当たり、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する材料供給にかかると継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。本件根抵当権につ

第398条の22(根抵当権の消滅請求)

- ① 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えたときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
- ② 第398条の16の登記がされている根抵当権は、1個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
- ③ 第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。

◇趣旨

根抵当権は目的不動産に対する独立の担保価値、すなわら極度額という種の支配権という性格を有するため、極度額に相当する金額が提供されさえすれば、物上保証人などの利害関係人に対する関係では根抵当権を消滅させても構わないため、かかる消滅請求を認めた。

[21-29-1] Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの抵当権は、確定的に消滅する。[○]

[28-31-5] Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA-B間の継続的売買に係る売却代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。元本が確定し、被担保債権額が1億2,000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。[○]

(根抵当権まとの事項確定前確定後債務者の変更(398条の4)可不可被担保債権の範囲の変更(398条の4)可不可極度額の変更(398条の5)可不可元本確定期日の変更(398条の6)可\*1可\*1相続による包括承継(398条の8)可不可合併による包括承継(398条の9)可不可全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡(398条の12、398条の13)可\*2可\*2可転抵当(398条の11)可可\*1利害関係人全員の承諾が必要である。\*2 根抵当権設定者の承諾が必要である。第5